



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/512/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:
נציגות הבית המשותף בשדרות ירושלים 42 כפר סבא
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת.ד. 548, כפר סבא
טל': 052-5776571 פקס: 09-7401175

נגד

הנתבעים:
1. פרחניק שמעון
2. דיין שמעון
באמצעות ב"כ: עו"ד ויטוריו דיין
יהושע בן גמלא 11, הוד השרון
טל': 053-7890307 פקס: 09-7947863

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם משטח קרקע בבית משותף המשמש אֶכְסְדֶרָה (שדרת עמודים מקורה ובשמה הלועזי קולונדה). בגדרה, נדרשתי לשאלה האם האכסדרה, המצויה בסמיכות ליחידה מסחרית בבית המשותף שבבעלות הנתבעים ומשמשה במסגרת פעילותה העסקית להצבת כסאות ושולחנות לאירוח באי המסעדה הפועלת בה, היא בגדר רכוש משותף כטענת התובעת או חלק מהנכס שבבעלות הנתבעים, למצער 'שטח ציבורי' כטענתם המאוחרת.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף בשדרות ירושלים 42 בכפר סבא, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 270 בגוש 6440 (להלן - "הבית המשותף").

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבעים, פרחניק שמעון ודיין שמעון (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם על פי הסכם בכתב בעלים של



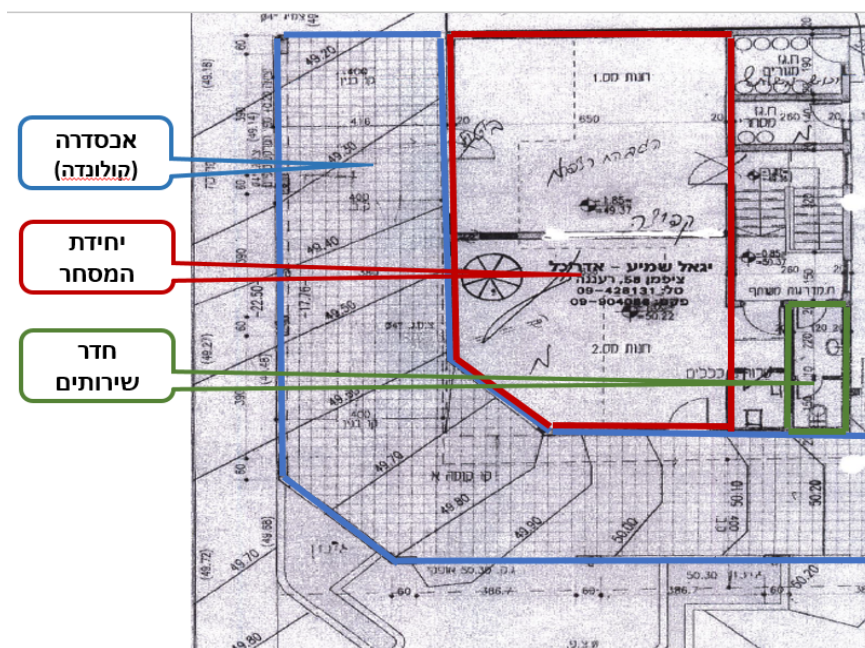
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יחידת המסחר בבית המשותף המשמשת מסעדה, משרשומה לטובתם בפנקס הזכויות הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), מיום 17.5.2016 (מס' שטר 19871/2016/10).

4. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 7 קומות. קומת המרתף וקומת הקרקע משמשות למסחר ומעליהן 5 קומות המשמשות למגורים. בקומת הקרקע אֶכְסְדָּה (קולונדה) שתקרתה מהווה רצפה למרפסות ולדירות שמעליה בבית המשותף (להלן - "האכסדרה"). האכסדרה מצויה בסמיכות ליחידת המסחר ומקיפה היחידה משלוש פאותיה. לשם הנוחות מצורף חלק מתשריט קומת הקרקע של הבית המשותף, אשר מוסכם על הצדדים כי הוכן על ידי האדריכל יגאל שמיע, וצורף לתכנית ההגשה (גרמושקה) בבקשה למתן היתר בניה:



5. ברקע הדברים, הסכם קומבינציה שנחתם ביום 25.12.1995 בין הבעלים של הקרקע שעליה בנוי הבית המשותף לחברה הקבלנית משכנות דוד קלאש בע"מ (להלן - "הקבלן"), לפיו בעלי הקרקע מכרו לקבלן "חלק מזכויותיהם בקרקע בתמורה לבניית דירות חדשות לבעלי הקרקע" (להלן - "הסכם הקומבינציה").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. הבית המשותף טרם נרשם בית משותף בפנקס הבתים המשותפים, ומשכך אין בפנקס המקרקעין בעניינו של בית זה (פנקס הזכויות) התייחסות לתתי חלקות, דירות המגורים ויחידת המסחר בבית המשותף על הצמדותיהן (ככל שיש כאלה על פי דין).

7. בכתב התביעה טענה התובעת כי ביום 28.6.2011 נכרת הסכם בין הנתבעים לבין בעלי הדירות בבית המשותף, לפיו ניתנה לנתבעים רשות שימוש ייחודי ב"חלק מהשטח המשותף בבניין" לתקופה של 7 שנים, תמורת תשלום דמי שימוש בסך של 14,000 ש"ח לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף (נספח ב' לכתב התביעה). התובעת לא פירטה בכתב התביעה השטח המדובר בבית המשותף, ולא טענה מפורשות לאכסדרה. אף בהסכם שצורף לכתב התביעה צוין שימוש הנתבעים "בחלק מהרכוש המשותף" מבלי שבא פירוט וזיהוי נוסף של שטח זה בבית המשותף. עוד כנטען בכתב התביעה, תוקף ההסכם פג ביום 27.6.2018, אך הנתבעים המשיכו לעשות שימוש ייחודי בשטח הרכוש המשותף שלא כדין ותוך הסגת גבול. לפיכך, עתרה התובעת למתן צו עשה המורה פינוי וסילוק יד הנתבעים משטח הרכוש המשותף. התובעת הוסיפה ועתרה להורות חיוב הנתבעים לשלם לתובעת סך של 6,744 ש"ח, חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה") לתקופה שמחודש נובמבר 2017 ועד לחודש אוקטובר 2018, בגין היחידה המסחרית שבבעלותם. בנוסף, עתרה התובעת להורות חיוב הנתבע 1 לשלם סך של 2,400 ש"ח, חלקו בהוצאות החזקה בגין דירה אחרת שבבעלותו בבית המשותף.

8. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעים טענות התובעת ועתרו לדחיית התביעה. כנטען, ההסכם שצורף לכתב התביעה הסדיר השימוש שנעשה על ידי הנתבעים בחלק משטח הבית המשותף ודמי השימוש בגינו עד למועד החתימה על ההסכם, דהיינו, משנת 2004 ועד ליום 28.6.2011. במועד זה נחתם הסכם נוסף בין הנתבעים לבין בעלי הדירות, המסדיר, כך לשון כתב ההגנה, "בעלות הנתבעים על הנכס שבנדון" (נספח א' לכתב ההגנה). בהתאם להסכם, תמורת הממכר שילמו הנתבעים סך של 5,000 ש"ח לכל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. עיון בהסכם שצורף לכתב ההגנה, העלה כי מדובר בחלל פנימי בבית המשותף (שאינו האכסדרה) ששטחו כ-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2 מ"ר, המסומן בתשריט דלעיל חדר שירותים (להלן - "חדר השירותים"). כנטען, הסכם המכר נחתם בנפרד מההסכם שנחתם בין הצדדים להסדרת תשלום דמי השימוש בממכר עבור 7 השנים שקדמו למועד רכישתו. עוד כנטען, התובעת הסתירה דבר קיומו של הסכם זה בחוסר תום לב, תוך העלמת עובדות רלוונטיות מכתב התביעה ודי באמור כדי לדחות התביעה. זאת, אף לגופם של דברים משטח הרכוש המשותף נמכר כדין לנתבעים. אשר לסעד הכספי, טענו הנתבעים כי יש לדחותו משלא נטען הבסיס לחיובם בתשלום זה.

9. ביום 25.3.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט.

במסגרתה, הבהירה התובעת, לראשונה, כי השטח מושא המחלוקת הוא שטח האכסדרה. בתוך כך, אישרה התובעת כי ביום 28.6.2011 נחתם הסכם למכירת חדר השירותים לנתבעים. עם זאת, לדידה, ההסכם הנוסף שנחתם בין הצדדים במועד זה ביקש להסדיר השימוש ודמי השימוש בשטח אחר, שטח האכסדרה, לתקופה של 7 שנים הצופה פני עתיד. הנתבעים הכחישו מכל וכל טענה זו, בהדגישם כי ההסכמים הסדירו אך ממכר חדר השירותים, המשמש חלק ממטבח המסעדה, ותשלום דמי שימוש ב-7 השנים שקדמו לשימושם הייחודי של הנתבעים בשטח זה. שטח האכסדרה מעולם לא היה נושא להסכם בין הצדדים. לטענת הנתבעים, שטח האכסדרה משמש הנכס שבבעלותם (מסעדה), משמוצבים בו כסאות ושולחנות לשימוש אורחי המסעדה. עוד כנטען, במסגרת הסכם המכר לרכישת היחידה המסחרית בבית המשותף צוין במפורש כי "המרפסות המקורות" (האכסדרה) מהוות חלק בלתי נפרד מהיחידה המסחרית בבית המשותף.

10. בהחלטה ממועד הדיון הורתי, בהסכמת הצדדים, כי הנתבעים ימציאו הסכם רכישת היחידה המסחרית על ידם, לאחריה תודיע התובעת עמדתה לעניין המשך בירור התביעה. עוד במעמד ישיבת קדם המשפט, ניתן פסק דין חלקי, המסיים המחלוקת הכספית שניטשה בין הצדדים לעניין תשלום הוצאות החזקה, מושא כתב התביעה.

11. ביום 7.4.2019 הגישו הנתבעים הסכם מכר מיום 19.2.2002, לפיו רכשו הנתבעים מהקבלן "חנות מרתף בקומת הקרקע" בבית משותף. הנתבעים צירפו להודעתם מסמכים נוספים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. בהתאם להחלטה מיום 25.3.2019, הודיעה התובעת ביום 28.4.2019 כי כעולה מהסכם המכר אין הממכר כולל הצמדה של חלק כלשהו מהרכוש המשותף ליחידה המסחרית, ובכלל זאת שטח האכסדרה. לפיכך, עמדה על המשך בירור התביעה.

13. תגובת הנתבעים התקבלה אך ביום 10.7.2019. לנוכח האמור בה, הורתי בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.

14. התובעת הגישה תצהירו של חבר נציגות הבית המשותף, מר אלון בן דור, תצהיר עדות ראשית מטעמה. הנתבעים הגישו תצהירו של הנתבע 2 תצהיר עדות ראשית מטעמם.

15. בפתח הדיון שהתקיים לפניי ביום 25.12.2019, הבהרתי לתובעת, בזהירות הראויה, כי סבורני שההסכם מיום 28.6.2011, המסדיר תשלום דמי שימוש בגין "חלק מהרכוש המשותף" (ללא זיהוי), מתייחס לחדר השירותים בבית המשותף, בבחינת הסכם משלים להסכם שנחתם בין הצדדים במועד זה למכירת חדר השירותים לנתבעים. זאת, בניגוד לעמדת התובעת, לרבות כנטען בתצהיר עדותה הראשית, לפיה ההסכם הסדיר תשלום דמי שימוש (צופה פני עתיד) בגין שימוש הנתבעים בשטח האכסדרה, ללמדנו לשיטתה היות שטח זה רכוש משותף שאינו בבעלות הנתבעים.

בתוך כך, באו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה לצורך הכרעה בסעד לסילוק יד ידרשו הצדדים לשאלה מהן זכויות הקבלן בהתאם להסכם הקומבינציה, האם כוללות שטח האכסדרה, אם לאו. זאת, משהוסכם על הצדדים במעמד הדיון כי במסגרת הסכם המכר מיום 19.2.2002, רכשו הנתבעים מהקבלן מלוא זכויותיו בבית המשותף כפי שהיו במועד זה. בהתאם, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית משלימים ומועד ישיבה לשמיעת הראיות.

16. התובעת הגישה תצהירם של מר אלון בן דור, חבר נציגות הבית המשותף, ושל גרשון פולג, בעל זכויות בקרקע, תצהירי עדות ראשית מטעמה. הנתבעים הגישו תצהירם של הנתבע 2, של עורך הדין יצהר הס ושל האדריכל יגאל שמי, תצהירי עדות ראשית מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. ביום 4.6.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות. בפתחה הודיע בא כוח הנתבעים כי מטעמים רפואיים נבצר מעורך הדין הס ומהאדריכל שמיע להתייצב לחקירה על תצהירם, ומבוקש כי יקבע מועד דיון נוסף לחקירתם. בישיבה זו נחקרו המצהירים מטעם הצדדים - הנתבע 2, מר בן דור ומר פולג - על תצהירם. בהסכמת הצדדים, הורתי מועד ישיבה נוסף לשמיעת הראיות, שאליו הוזמנו עדים נוספים כמבוקש על ידי הצדדים.

18. ביני וביני, קיימתי בהסכמת הצדדים ביקור בבית המשותף, בניסיון לסייע בדי הצדדים לסיים המחלוקת בפשרה. במסגרתו, צפיתי באכסדרה וביחידת המסחר שבבעלות הנתבעים בבית המשותף. ברם, אף לאחריו וחרף מתווה פשרה שביקשו הנתבעים לשקול, עמדו אלה, בסופו של יום, על טענתם לפיה האכסדרה מהווה חלק מיחידת המסחר שבבעלותם בבית המשותף.

19. ביום 2.8.2020 התקיימה לפניי ישיבה נוספת לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו עורך הדין הס והאדריכל יגאל שמיע, מצהירים מטעם הנתבעים. בגמר הדיון, הודיעו הצדדים כי הם מבקשים לשקול מתווה לסיום המחלוקת בפשרה, לפיו הנתבעים ישלמו לתובעת דמי שימוש בגין השימוש בשטח האכסדרה בסך של 1,500 ש"ח לחודש, מחודש אוגוסט 2019 ואילך. הסכם פשרה זה יעמוד בתקפו עד לרישום הבית המשותף ומבלי שיהא בו כדי לגרוע מטענות הצדדים לעניין זכויותיהם באכסדרה.

20. תחת תגובתם המשותפת של הצדדים באשר לסיום המחלוקת, התקבלה עמדת הנתבעים בגדרה טעמי התנגדותם למתווה הפשרה. בנסיבות אלה, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

21. הצדדים הגישו כתבי סיכומיהם. אביא להלן עיקרי טענותיהם.

עיקרי טענות הצדדים

22. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. עיון בהסכם המכר מכוחו רכשו הנתבעים יחידת המסחר מהקבלן העלה כי הממכר אינו כולל הצמדה כלשהי, לרבות שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האכסדרה המקיף את יחידת המסחר. אף בהסכם הקומבינציה אין כדי להעניק לנתבעים זכויות בשטח האכסדרה, כנתמך בעדותו של מר פולג, בעלים של הקרקע וצד להסכם זה. בהתאם להוראות הדין, משלא הוצמדה האכסדרה למי מדירות הבית המשותף, ובכללן ליחידת המסחר, יש לראותה רכוש משותף. זאת, כנתמך בדבריו המפורשים של הנתבע 2 בישיבת קדם משפט, וכן בעדות האדריכל שמיע, לפיה האכסדרה נועדה לשמש מעבר מקורה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, כדרישת העירייה. שימוש שעשו הנתבעים בשטח האכסדרה במרוצת השנים חוסה תחת רשות שימוש במקרקעין, כפי הסכמה מכללא שניתנה בידי הנתבעים על ידי בעלי הדירות בבית המשותף, אשר ניתן להפסיקה בכל עת. לפיכך, עתרה התובעת להורות סילוק יד הנתבעים מהאכסדרה, תוך חיובם בהוצאות משפט.

23. מנגד, טענו הנתבעים כי דין התביעה להידחות. בכתב הסיכומים העלו הנתבעים, לראשונה, הטענה כי האכסדרה מהווה 'שטח ציבורי' שאינו נמנה כלל עם חלקי הבית המשותף. זאת, בניגוד לטענתם בכתב ההגנה ובתצהיר עדותם הראשית, לפיה שטח האכסדרה הוצמד ליחידת המסחר ובבעלות הנתבעים. כך בהפנותם לדברי מר פולג בעדותו ולהסכם הקומבינציה. לדידם, שטח האכסדרה לא צוין במפורש בהסכם הקומבינציה כ"מרפסות מקורות" - כמצוין בהסכם להשכרת יחידת המסחר לצד שלישי על ידי הקבלן עובר לרכישת היחידה על ידי הנתבעים - הואיל ובמועד החתימה על הסכם הקומבינציה טרם נבנה הבית המשותף. ברם, "מהותו לא שונתה והוא ממשיך להיות שטח מעבר ציבורי המהווה דרך גישה בלעדית לחלק המסחרי", כך לשון הנתבעים בכתב הסיכומים. עוד כנטען, לא עלה בידי התובעת להוכיח כי האכסדרה מהווה רכוש משותף, משלא צורף תשריט לבסס טענה זו. בד בבד, שבו הנתבעים על טענתם לפיה שטח האכסדרה "שייך לחלק המסחרי", עת בעלי הדירות ראו בו "שטח הצמוד לחלק המסחרי", וכי עם רישום הבית המשותף שטח האכסדרה "יוצמד לשטח המסחרי הכלול ביחידות הקבלן, מן הטעם הפשוט שבמאזן הנוחות מתקיים הכלל 'זה נהנה וזה לא חסר' ושום נזק לא ייגרם לשאר דיירי הבניין", כך לשון הנתבעים. בהתאם, נשאו הנתבעים במשך כ-20 שנה בתשלומי הארנונה בגין שימוש באכסדרה, המשמשת מעבר וגישה ההכרחיים לפעילות יחידת המסחר. לפיכך, עתרו לדחיית התביעה, עד להכרעת בית משפט מוסמך במעמד שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האכסדרה, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט. בשולי טענותיהם בכתב הסיכומים, הוסיפו הנתבעים וטענו כי אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון בתביעה דנן, בציינם כי הכרעה "במעמד המעבר" מסור "לערכאה מוסמכת", הא ותו לאו.

24. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

25. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר ששקלתי מלוא טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא טעמי למסקנה זו.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה

26. תחילה, הגם שנטען בשולי הדברים ולראשונה בכתב הסיכומים, הנני לדחות טענת הנתבעים להעדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן לנוכח הסעד המבוקש בגדרה. הוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין מורנו, במפורש, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף", בבחינת סמכות מקבילה לסמכות בית משפט מוסמך, אשר התובע רשאי להביאו, לפי בחירתו, לפני אחד משני אלה.

27. הוראת סעיף 73(3) לחוק המקרקעין מרחיבה מיהות הצדדים הרשאים להביא סכסוך להכרעת המפקח, בקבעה כי אף נציגות הבית המשותף נמנית עם אלה. אוסיף, הגם שלא נטען על ידי הנתבעים, כי הגשת התביעה דנן שעילתה הסגת גבול לרכוש משותף בבית המשותף באה בגדר הרשאת התובעת, נציגות הבית המשותף, בהיותה קשורה במישרין בסמכות הנציגות ובחובתה לדאוג להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולניהולו, כקבוע בהוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין. בכלל זאת, הסמכות לפעול להגשת תביעה בגין שימוש הנעשה לשיטתה ברכוש משותף בבית המשותף על ידי בעלים של דירה והמחזיק מטעמו, כנטען בענייננו, תוך תפיסת חזקה ייחודית על ידם ברכוש זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. בנוסף, אין בהידרש המפקח על רישום מקרקעין לסוגיה שעניינה היקף הזכויות באכסדרה, אגב הכרעה בתביעה שעילתה הסגת גבול, כדי לשלול סמכותו העניינית לדון בתביעה. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, לאמור: "הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור הענין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר". מכוחה של הוראת דין זו, רשאי המפקח על רישום מקרקעין להכריע בשאלת היקף הזכויות באכסדרה - אגב בירור טענת הסגת גבול לרכוש משותף - אף אם מחלוקת זו אינה בגדרי סמכותו העניינית, מבלי שהכרעה בעניין זה תהווה מעשה בית דין (ראו גם: ע"א 10112/03 פת נ' קטלן-אסן, פסקאות 23-24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (4.10.2009)).

מעמדה המשפטי של האכסדרה

29. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בטענת התובעת בדבר הסגת גבול הנתבעים לשטח האכסדרה. בגדרה, על המדוכה, השאלה האם האכסדרה היא רכוש משותף כטענת התובעת או שמא מהווה חלק מיחידת המסחר שבבעלות הנתבעים או 'שטח ציבורי' כטענתם המאוחרת.

30. כאמור, הבית המשותף מושא התביעה שלפניי טרם נרשם בית משותף. בעניינו של בית זה חלות הוראות פרק ו' 1 לחוק המקרקעין. בכלל זאת, הוראת סעיף 77א לחוק המקרקעין המגדירה 'רכוש משותף' בבית שטרם נרשם בית משותף, לאמור: "כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת" (ההדגשות אינן במקור). הגדרה זו זהה להגדרת 'רכוש משותף' בבית שנרשם בית משותף, כקבוע בהוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, למעט לעניין זיהוי הדירות ככאלה הרשומות בפנקס הבתים המשותפים ("כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות"). רישום שמשמעו זיהוי כל דירה כתת חלקה על הצמדותיה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. הגדרת הרכוש המשותף בבית היא הגדרה שיוורית. כל מה שאינו רשום דירה הוא בגדר רכוש משותף (פרופ' י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), 392).
32. הוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, החלה כאמור על בית שנרשם בית משותף, מורנו כי בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון החל על הבית המשותף "שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". אין בפרק ו'1 לחוק המקרקעין הוראה דומה, וזו אף הוחרגה במפורש מהוראות פרק ו' החלות על בית משותף שטרם נרשם, כמפורט בסעיף 77ב לחוק.
33. כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, פרק ו'1 לחוק "דן בהסדרים בדבר ניהולו של הבית, שטרם נרשם בית משותף, ואיננו דן בזכויות קנייניות" (ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 687 (1986)). משכך, אין גם לראות בהגדרת 'רכוש משותף' שבסעיף 77א לחוק "כבאה להעניק לרכוש זה הגדרה קניינית. המבחן, על פי הגדרה זו, להיות הרכוש 'רכוש משותף' הוא מבחן הייעוד בלבד. במלים אחרות, חלקיו של ה'רכוש המשותף', כפי ששמו מעיד עליו הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם" (ע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987) (להלן - עניין בן צור); ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 854 (1993); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובר נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 399-400 (2001) (להלן - עניין סופיוב)).
34. בעניין בן צור, הוסיף כבוד השופט א' גולדברג ועמד על המשמעות שיש ליתן למבחן הייעוד, על פיו יקבעו אילו חלקים בבית מיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם, לאמור: "נוכח מסקנתנו כי זכויותיהם של 'בעלי' הדירות ב'רכוש המשותף' אינן נקבעות על פי חוק, אין מנוס מלתת למבחן הייעוד משמעות כפולה. האחת, כי אותם חלקי הבית מיועדים על פי מהותם לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. והמשמעות האחרת, כי בידי כל בעלי הדירות או מרביתם זכות לעשות שימוש בחלק או בחלקים אלה של הבית, שהוענקה להם על ידי מי שבכוחו להעניק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכות כזאת. אך מובן הוא, כי רק בהצטברן של שתי המשמעויות הופך אותו חלק מהבית ל'רכוש משותף' לענין פרק ו'1. שאם נתקיימה רק המשמעות הראשונה (המשמעות 'הטכנית') ואף על פי כן אין ל'בעלי' הדירות או למרביתם זכות על פי הסכם ה'רכישה', להשתמש בחלק זה של הבניין (כגון שזכות השימוש במעלית קיימת בידי בעל דירה אחת), פשיטא, שאין לראות את הרכוש האמור כ'רכוש משותף', ואין לאסיפה הכללית של 'בעלי' הדירות עניין לענות בו" (שם, 150; ההדגשות אינן במקור).

35. אוסיף, כי בפסיקה מאוחרת הוצעה גישה פרשנית, לפיה יש להחיל את 'מבחן הייעוד' אך על אותם מתקנים הנזכרים בסיפא סעיף 77א לחוק, משיש לראות בחלקי הבית המשותף כמפורט ברישא הסעיף ("הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים") רכוש משותף, מעצם טיבם וטבעם (ע"א 8148/06 אליהו נ' שימבורסקי, פסקה 11 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.2008) (להלן - עניין אליהו)).

36. על רקע דברים אלה, אפנה לבחון האם האכסדרה היא רכוש משותף, אם לאו.

37. אין חולק כי האכסדרה מצויה במפלס הקרקע בבית המשותף, בתווך שבין היחידה המסחרית שבבעלות הנתבעים לקווי הבנין, עת תקרתה מהווה רצפת מרפסות ודירות המגורים בבית המשותף. עוד אין חולק, כי האכסדרה משמשת מעבר מקורה וגישה ליחידת המסחר בבית המשותף ולשטחי מסחר המצויים בהמשכה הרציף לאכסדרה בבניין הסמוך לבית המשותף. כך, כפי שנוכחתי לראות אף בביקורי בבית המשותף. כך, אף כפי שהעיד האדריכל שמיע, מטעם הנתבעים, אשר הגיש הבקשה להיתר בניה לבניית הבית המשותף, באמרו בהתייחס לאכסדרה: "זו היתה דרישה של העירייה לספק מעבר מקורה, בחזית של שטחים מסחריים" (פרוטוקול דיון מיום 2.8.2020, עמוד 4 שורות 27-29). לשאלה מהו 'מעבר מקורה', הוסיף האדריכל שמיע והעיד: "אנו מכירים את זה בכל הערים, במיוחד בכפר סבא. לכל שטח מסחרי יש בחזית שטח מקורה ברוחב של בין 3-5 מ'. השימוש כבר לא עניין של התכנון שלי, גם העירייה לא דורשת להתייחס לשימוש. כל הציבור יכול להשתמש בחזית כדי להיכנס לפונקציה המסחרית" (שם, עמוד 5 שורות 2-6). לפיכך, דומה כי אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חולק שהאכסדרה, על פי מהותה, מיועדת לשמש את כל בעלי הדירות בבית המשותף או מרביתם.

38. אשר למבחן הזכות, לאחר שעיינתי במלוא התשתית הראייתית שהונחה לפניי, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי הנתבעים להוכיח זכות שהוענקה להם באופן ייחודי ובלעדי באכסדרה. הטעמים למסקנה זו הם אלה:

39. ראשית, לנוכח טענותיהם הסותרות של הנתבעים-הם, באשר להיקף זכויותיהם בשטח האכסדרה. מחד גיסא, טענו כי האכסדרה היא 'שטח ציבורי' המשמש דרך גישה בלעדית ליחידה המסחרית שבבעלותם בבית המשותף, המצויה למעשה בבעלות עיריית כפר סבא. מאידך גיסא, טענו כי בהתאם להסכם הקומבינציה, אשר במסגרתו נמכרו חלק מזכויות בעלי הקרקע לקבלן, הוצמדה האכסדרה ליחידה המסחרית אשר נרכשה על ידי הנתבעים מהקבלן. ברי, כי טענות אלה אינן יכולות לדור בכפיפה. למצער, יש בהן כדי לבסס הטענה כי אין לנתבעים זכות ייחודית ובלעדית באכסדרה, במובחן מזכויות יתר בעלי הדירות בבית המשותף בשטח זה. משלא עלה בידי הנתבעים להוכיח טענתם בדבר היות האכסדרה 'שטח ציבורי' (להלן) - ומבלי שאדרש לנפקות העלתה אך בכתב הסיכומים, בבחינת הרחבת חזית אסורה - ברי כי משמעות הדבר היא שהאכסדרה מהווה רכוש משותף.

40. שנית, משעיון במערכת ההסכמית שהונחה לפניי אינה מלמדת כי האכסדרה הוצאה מן הרכוש המשותף והיותה חלק מזכויות הקבלן בבית המשותף, אשר לימים נמכרו במלואן לנתבעים. אפרט:

א. אין חולק כי הסכם הקומבינציה שנחתם בין בעלי הקרקע לקבלן אינו כולל התייחסות מפורשת לאכסדרה ואף לא לרכוש המשותף בבית המשותף. תחת "מכר ותמורה" הוסכם על הצדדים להסכם כי "הבעלים מתחייב למכור ולהעביר לקבלן והקבלן מתחייב לרכוש ולקבל בהעברה מהבעלים את מקרקעי הקבלן וזאת בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה במלואם, במדויק ובמועד, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בתמורה לבניית כל יחידות הבעלים עבור הבעלים, השלמתם ומסירתם לבעלים בהתאם להוראות חוזה זה" (סעיף 4(א) להסכם הקומבינציה; ההדגשות אינן במקור). 'מקרקעי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקבלן' הוגדרו בסעיף 1 להסכם: "שטח הקרקע מתוך המקרקעין שעליו יבנו יחידות הקבלן לרבות השטח המסחרי". 'יחידות הקבלן' הוגדרו בסעיף 1 להסכם: "סך כל היחידות בבנין לרבות כל השטח המסחרי פחות יחידות הבעלים". אשר ל'יחידות הבעלים' אלה הוגדרו בסעיף זה: "4 דירות בבנין בנות 5 חדרים חדרים כל אחת ... לרבות 4 מחסנים ... לרבות 2 חניות מקורות. ... והכל על פי המפרט הטכני והתוכניות".

ב. כאמור, אין בהסכם הקומבינציה התייחסות מפורשת לחלקי הבית המשותף המהווים רכוש משותף. בכלל זאת, אין בהסכם הקומבינציה הגדרה מהו הרכוש המשותף במבנה. כפי שהעיד בענין זה מר פולג, מבעלי הקרקע אשר היה צד להסכם, הצדדים ביקשו להסדיר בהסכם אך העקרון לפיו "תמורת 50% מהמבונה על פי זכויות הבניה, הקבלן יבצע את עבודות הבניה" (סעיף 2 לתצהיר). כלשונו בחקירתו הנגדית "יכול להיות שבחכמה בדיעבד נכון יותר לעשות הסכם קומבינציה לאחר שיש תכנית אדריכלית מוסכמת". בתוך כך, אישר העד כי בהעדרה של תכנית אדריכלית במעמד החתימה על ההסכם, אף לא באה התייחסות ספציפית למשמעות ההיגדים 'מקרקעי הקבלן' ו-'יחידות הקבלן' וממילא להיות האכסדרה חלק מהתמורה לקבלן (פרוטוקול דיון מיום 4.6.2020, עמוד 18 שורות 1-16).

ג. אין בשתיקת הסכם הקומבינציה לעניין הגדרת הרכוש המשותף כדי ללמד הסכמה לפיה לא ייותר בבית המשותף רכוש משותף, אשר יוצמד בהתאם להסכם למי מדירות הבית המשותף ובכללן ליחידה המסחרית. זאת, משאין חולק כי לאחר השלמת הבניה ועד היום בבית המשותף ישנו רכוש משותף - אשר מעמדו ככזה אינו שנוי במחלוקת - הכולל, בין היתר, שטח חניה במפלס הקרקע, חדר מדרגות, חדר אשפה, חדרי גז וחלק משטח גג הבית המשותף (ראו גם: פרוטוקול דיון מיום 4.6.2020, עמוד 12 שורות 4-11). בתוך כך, מוסכם אף על הנתבעים כי חדר השירותים, אשר נמכר להם לימים ובגינו אף שילמו לבעלי הדירות בבית המשותף דמי שימוש לתקופה של 7 שנים קודם להסכם המכר (הסכמים מיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28.6.2011), היווה אף הוא חלק מהרכוש המשותף בבית המשותף, הגם שלא בא זכרו במפורש בהסכם הקומבינציה.

ד. למותר אף לציין כי בהתייחס לדירות בעלי הקרקע, באה התייחסות מפורשת בהסכם הקומבינציה להצמדות לדירות אלה, הכוללות "מחסן" ו"חניה מקורה" (סעיף 1 להסכם), ללמדנו, כי הצדדים נתנו דעתם לגריעה של חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות המגורים של בעלי הקרקע. משלא קבעו גריעה של האכסדרה מחלקי הרכוש המשותף והצמדתה ליחידה המסחרית, חזקה היא כי הצדדים עשו כן ביודעין ובמכוון, בהותירם האכסדרה, כמו גם חלקים אחרים ברכוש המשותף כמפורט לעיל, בגדרי הרכוש המשותף בבית. זאת, אף בשים לב לערך הכלכלי שבצדה של זכות זו באכסדרה, ומשניתן היה לצפות מהקבלן, אשר זו מומחיותו ותחום עיסוקו, לדרוש לציין במפורש היות האכסדרה חלק מהיחידה המסחרית.

ה. בהקשר זה, מורנו ההלכה הפסוקה כי גריעה של חלק מהרכוש המשותף לטובת הצמדתו לדירה בבית המשותף כפופה להסכמת שאר בעלי הדירות, בדרך המוכרת על פי דין, אף אם מדובר בבית שטרם נרשם בית משותף. כפי שהוסיפה ושנתה כבוד השופטת א' פרוקצ'יה בעניין סופיוב "במסגרת הסכמה כזו נדרש כי בחוזה מכר עם דייר יצוינו במפרט הפרטים הנוגעים לגריעה כזו ואין בעניין זה הבדל בין בית משותף שנרשם לזה שטרם נרשם כאמור". בתוך כך, נקבע כי "גריעה מהשטח המשותף חייבת להיות מפורשת בכתובים ועליה להיות מוצגת באורח קונקרטי" (שם, 400-402; עניין אליהו, פסקאות 9-10 לפסק הדין).

ו. בענייננו, אין אף בהסכם המכר שנחתם בין הקבלן לנתבעים ביום 19.2.2002 כל התייחסות לרכישת זכות כלשהי באכסדרה, אגב גריעתו מחלקי הרכוש המשותף. ה"ממכר" הוגדר בהסכם זה "חנות מרתף בקומת הקרקע בבניין ברחוב ירושלים 53 בכפר סבא..." (נספח ב' לתצהיר עדותם הראשית של הנתבעים).

ראשית, ספק אם הסכם זה חל על היחידה המסחרית בבית המשותף, משאין חולק כי כתובתו ברחוב שדרות ירושלים 42 בכפר סבא.

שנית, אין כאמור בהסכם כל התייחסות להיות הממכר כולל שטח האכסדרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שלישית, אף אם הסכם זה הוא המסדיר רכישת היחידה המסחרית בבית המשותף (אין חולק כי הנתבעים הם בעלי הזכויות ביחידה זו), הרי שבהתאם לו קיבלו על עצמם הנתבעים את כל התחייבויות הקבלן וזכויותיו כלפי שוכר המחזיק בממכר. הסכם השכירות שנחתם בין הקבלן לשוכר מיום 14.6.2000 צורף להסכם המכר (נספח ג' לתצהיר עדותם הראשית של הנתבעים). עיון בהסכם השכירות, העלה כי בגדרו הוגדר ה"מושכר" כ"חנות + מרתף + מרפסות מקורות לפי תשריט רצ"ב בקומת הקרקע בבנין ... ברחוב ירושלים 42 בכ"ס". סבורני כי השמטת המילים "מרפסות מקורות" (האכסדרה לשיטת הנתבעים), מהסכם המכר, אינה מקרית, וזו נפקדה מהסכם זה משלא היה בידי הקבלן למכור יותר מכפי זכויותיו בבית המשותף. בעניין זה, העיד הנתבע 2 כי עורך הדין שייצג הנתבעים בעסקה זו היה "עורך דין מזדמן", אשר "לא האיר את עיניי שזה לא כתוב בהסכם המכר. סמכתי על עורך הדין שלי ועל עורך הדין של הבניין". כך אף בהמשכם של דברים, באמרו "לקחתי עורך דין כנראה לא היה עירני מספיק כדי שירשמו גם את המרפסות המקורות" (פרוטוקול דיון מיום 4.6.2020, עמוד 2 שורות 25-28, עמוד 3 שורות 3-4 ועמוד 5 שורות 10-18).

ז. חרף ארכות שנתתי בידי הנתבעים להביא ראיותיהם, לרבות העדת גורמים רלוונטיים אשר יכולים לשפוך אור הן על עסקת הקומבינציה הן על עסקת המכר שבין הקבלן לנתבעים, לא עלה בידי הנתבעים לעשות כן. למעט חלק מתשריט הבית המשותף אשר צורף לבקשה להיתר בניה, לא הובא כל תשריט ומפרט, תימוכין להיקף זכויות הנתבעים ביחידה המסחרית הכולל זכות ייחודית באכסדרה. מטעם הנתבעים העיד בעניין זה אך האדריכל שמיע, אשר הכין תכנית ההגשה בבקשה להיתר בניה לבניית הבית המשותף. לשאלה האם במסגרת תכנית זו הוצמדה האכסדרה ליחידה המסחרית, השיב העד בבהירות ובפשטות בשלילה (פרוטוקול דיון מיום 2.8.2020, עמוד 4 שורות 14-16). כך, אף בהמשכם של דברים, בהבהירו ללא כחל וסרק, "ברגע שזה קולונדה אני לא יכול להצמיד", בהדגישו כי התכנון היה "כל כולו לבקשת הקבלן בשיתוף בעלי הקרקע" (שם, עמוד 5 שורות 19 ו-30).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ח. בעמדה זו החזיק אף הנתבע 2, כעולה מדבריו בישיבת קדם משפט ראשונה שהתקיימה לפניי, לפיהם "מעולם לא טענו לזכויות קניין בחלק המסומן בכחול בתסריט [האכסדרה]" (פרוטוקול דיון מיום 25.3.2019, עמוד 2 שורה 18). בהמשכם של דברים, הוסיף וטען כי מדובר ב"שטח רכוש משותף" שהקבלן "הצמיד פיסית" ליחידת המסחר (שם, שורה 24).

41. **שלישית**, בהעדר הוראה מפורשת במערכת ההסכמית שבין הצדדים דלעיל, בדבר גריעה האכסדרה מחלקי הרכוש המשותף והצמדתה ליחידה המסחרית בבית, יחולו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. זאת, בהתאם להוראת סעיף 77ג לחוק, המורנו כי "בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת". בהיקש מהוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, לא ניתן לשנות זכויותיו של בעל דירה בבית המשותף, בכלל זאת גריעת חלק מהרכוש המשותף לשימושו הייחודי של בעל דירה אחרת בבית, אלא בהסכמתו. כאמור, לא הוכחה לפניי כל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף להוצאת האכסדרה מחלקי הרכוש המשותף ומתן זכות שימוש בלעדי ותפיסת חזקה ייחודית בה לנתבעים.

42. **רביעית**, משאין בתשלום ארנונה בגין שימוש באכסדרה כדי ללמד זכויות קניין של הנתבעים בשטח זה. כאמור, הנתבעים ביקשו לבסס זכות ייחודית באכסדרה אף בתשלום ארנונה לעיריית כפר סבא בגין השימוש באכסדרה במשך כ-20 שנה. לבד מכך שבהתאם להוראות הדין, חל החיוב בתשלום ארנונה על המחזיק בנכס (ולא על הבעלים) בגין השימוש הנעשה בנכס, ברי כי אין בכך כדי להקנות זכות קניין בנכס. בעניין זה, מורנו הוראת סעיף 161 לחוק המקרקעין, במפורש, "מתחילת חוק זה אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק". סבורני כי שימוש ייחודי זה הנעשה על ידי הנתבעים במשך שנים רבות באכסדרה, הכולל הצבת שולחנות וכסאות דרך קבע בשעות פעילות המסעדה, חוסה תחת דיני רישיון במקרקעין (להלן).

43. לא זו אף זו, היתר הניתן על ידי עיריית כפר סבא להצבת שולחנות וכסאות באכסדרה, ככל שניתן כטענת הנתבעים, נעשה ללא קשר לזכויות הקניין בנכס שבו מבוצעת הפעילות, אלא בקשר לפעילות עצמה. זאת, בדומה למתן רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אשר משמעו כי ההיתר הוא חוקי על פי חוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה (ראו גם: ע"א 2527/08 (מחוזי ת"א) פולק נ' בן מאור, פסקה 29 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (21.7.2010)). בענייננו, אין חולק כי היחידה המסחרית מושכרת מזה שנים רבות לאחר, המחזיק בה ומפעיל בה מסעדה. ככל שניתן היתר להצבת שולחנות וכסאות באכסדרה, זה ניתן בידי המחזיקים ביחידה המסחרית בבית המשותף (שוכרים לשעה) מטעם הנתבעים, המבצעים בה הפעילות העסקית, ומבלי שיש בהיתר זה כדי להעניק למי מהם זכות או רשות שימוש באכסדרה וממילא זכות קניין בה.

44. **חמישית,** משלא הונחה לפניי תשתית ראייתית כלשהי לתמוך טענתם המאוחרת של הנתבעים - אשר כאמור עלתה לראשונה בכתב הסיכומים ודי בכך כדי לדחותה מחמת הרחבת חזית אסורה - בדבר היות האכסדרה 'שטח ציבורי'. הנתבעים מבקשים לתמוך טענה זו בהגיונם של דברים, משלדידם סיווג מעמדה המשפטי של האכסדרה 'רכוש משותף' משמעו שלילת גישה ומעבר ליחידה המסחרית. דומה כי בעניין זה נפלו הנתבעים לכדי שגגה. היות האכסדרה בגדר 'רכוש משותף' הוא המבטיח שימוש סביר ורגיל של כל בעלי הדירות בבית המשותף ומי מטעמם באכסדרה, בהתאם לייעודה, לרבות תוך מתן גישה ומעבר ליחידה המסחרית. ממילא, לא יכול מי מהם לקבל חזקה ייחודית באכסדרה, אשר יהא בה כדי לשלול זכות השימוש כאמור מכל בעלי הדירות האחרים.

45. מכל מקום, טענה בדבר מעמד האכסדרה 'שטח ציבורי' היה על הנתבעים לתמוך בתשתית ראייתית, לרבות באמצעות עדות נציג מטעם עיריית כפר סבא בדבר זכויותיה הקנייניות של העירייה באכסדרה. זאת לא נעשה. כדברי חברי המלומד, המפקח על רישום מקרקעין (כתוארו דאז): "לא כל קולונדה הינה חלק מ'רחוב' או 'מרחב ציבורי' ובוודאי שאיננה הופכת להיות, אוטומטית, בבעלות העירייה" (תביעה 5/285/2010 (מפקח על רישום מקרקעין ת"א) נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' צפריר, פורסם ב"נבו" (8.12.2011)). למותר לציין, כי אין חולק שהנתבעים ומי מטעמם אינם משלמים לעיריית כפר סבא דמי שימוש בגין השימוש הנעשה על ידם באכסדרה, ואף בטעם זה יש לשלול טענתם בדבר היות האכסדרה 'שטח ציבורי'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. אין גם בשימוש העד פולג (מבעלי הקרקע וצד להסכם הקומבינציה) בהיגד 'שטח ציבורי' בהתייחסו לאכסדרה, במסגרת העדות שנשמעה לפניי, כדי לסווג מעמדה המשפטי כאמור. כוונתו, כנלמד ממכלול הקשרי הדברים בעדותו, היתה להיות האכסדרה בשימוש הכלל (בעלי הדירות והיחידה המסחרית בבית המשותף) במובחן מזכות שימוש ייחודית שניתנה בה לפרט. דהיינו, היות האכסדרה 'רכוש משותף', בשם לב כי העד כלל לא נשאל על זכויות עיריית כפר סבא באכסדרה (פרוטוקול דיון מיום 4.6.2020, עמודים 18-19).

47. סיכומם של דברים, בהתאם למבחן הייעוד על מרכיביו, הנני לקבוע כי האכסדרה היא רכוש משותף על פי מהותה ומשלא הוענקה לנתבעים זכות ייחודית ובלעדית בה.

תפיסת חזקה ייחודית באכסדרה ורישיון במקרקעין

48. השימוש הנעשה על ידי הנתבעים ומי מטעמם במשך שנים רבות באכסדרה, הכולל הצבת שולחנות וכסאות לאירוח באי המסעדה, אינו בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש משותף, משעולה כדי תפיסת חזקה ייחודית. כפי ששניתי בהרחבה בפסק הדין שניתן בתביעה 6/90/2018 אנגלברג נ' שטרית, פורסם ב"נבו" (20.4.2020), שימוש ייחודי ברכוש המשותף חוסה תחת הלכות רישיון במקרקעין. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעלים של מקרקעין לאחר להחזיק או להשתמש בנכס, מבלי להקנות למקבל הרשות זכות במקרקעין. רשות כאמור יכולה להינתן במסגרת התקשרות חוזית בין בעל המקרקעין למקבל הרשות "ואפשר שתינתן על ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס" (פרופ' נ' זלצמן, רשיון במקרקעין, הפרקליט מב (תשנ"ה), 24). לאמור, הסכמה למתן רשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יכולה להיות אף הסכמה מכללא, הנלמדת מהתנהגות הצדדים בהעדר מחאה והתנגדות ולרבות שתיקת הצדדים.

49. סבורני, כי אלה הם פני הדברים בענייננו, משאף לשיטת הנתבעים לא באה כל התקשרות חוזית בינם ומי מטעמם לבין בעלי הדירות בבית המשותף המסדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש הייחודי של הנתבעים באכסדרה. זו ניתנה בידי הנתבעים והמחזיקים מטעמם, במרוצת השנים, מכוח הסכמה מכללא. כאמור, בעניין זה לא מצאתי לקבל טענת התובעת כי הסכם מיום 28.6.2011 בדבר הסדרת תשלום דמי שימוש ב'חלק מהרכוש המשותף', עניינו באכסדרה. הסכם זה, הנעדר זיהוי מפורש של ה'חלק ברכוש המשותף', נחתם במועד שבו נחתם ההסכם למכירת חדר השירותים, אשר גם בגדרו לא בא ציון מפורש של שטח זה אלא אך 'חלק ברכוש המשותף'. בידי לקבל בעניין זה טענת הנתבעים, כי התקשרו בהסכם נוסף זה, משהובהר להם על ידי עורך הדין שייצגם בעסקת המכר כי לבעלי הדירות בבית המשותף הזכות לתבעם בגין תשלום דמי שימוש ראויים לתקופה של 7 שנים עד למועד המכירה. זאת כנתמך הן בעדות הנתבע 2 (פרוטוקול דיון מיום 4.6.2020, עמוד 3 שורות 24-27), הן בעדותו של עורך הדין הס שייצג הנתבעים בהסכם לרכישת חדר השירותים, לפיה "אם אני זוכר נכון, מקווה שאינני טועה, בהסכם היה משולב שני דברים, היתה קניה, היה שמאי שהציע שמאות, וגם דמי שימוש אחורה". לשאלה האם עניין האכסדרה עמד על הפרק והאם התבקש להתייחס אליו, השיב העד: "ממש לא" (פרוטוקול דיון מיום 2.8.2020, עמוד 2 שורות 27-31).

50. רשות מכללא, בדומה לכל רשות שאין בצדה כוונה ליצור התחייבות חוזית, רשאי בעל המקרקעין להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי מקבל הרשות כי אין הוא מוכן עוד להמשיכה (ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3) 78, 83 (1982); עניין סופיוב, 402). אך במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה (רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 27 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006); ע"א (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 לפסק הדין (5.10.2016)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

51. בנסיבות דנן, לא נטען וממילא לא הוכח על ידי הנתבעים כי ניתנה בידם רשות בלתי הדירה לשימוש ייחודי באכסדרה, אשר משמעה הקניית האכסדרה לשימוש הנתבעים לצמיתות. לפיכך, רשאים בעלי הדירות, לרבות באמצעות התובעת שחברה הוא בעלים של דירה בבית המשותף, להפסיקה, לרבות התניית המשך השימוש בה בתשלום דמי שימוש ראויים.

סוף דבר

52. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי דין התביעה להתקבל.
53. הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק ידם מהאכסדרה ולפנות כסאות, שולחנות וכל ציוד אחר הקשור בפעילות היחידה המסחרית, המוצבים בשטח האכסדרה. זאת, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
54. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין", אשר תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).
55. ביישמי אמות מידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה לאחר בירורה המלא, אשר כלל הגשת תצהירי עדות ראשית, חקירת העדים על תצהירם, לרבות בישיבה נוספת שנקבעה לשמיעת הראיות משנבצר מעדים מטעם הנתבעים להתייצב למועד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/512/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הישיבה הראשונה, וביקור שהתקיים בבית המשותף, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 10,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ז אלול תשפ"א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה